

《【문제3】 A시 시장 乙은 甲이 A시에서 진행하고 있는 공사가 관련 법령을 위반하였다는 이유로 해당 공사를 중지하는 명령을 하였다. 甲은 그 명령 이후에 그 원인이 사유가 소멸하였음을 들어 乙에 대하여 공사중지명령의 철회를 신청하였다. 그러나 乙은 그 원인이 사유가 소멸되지 않았다고 판단하여 甲의 신청에 대하여 아무런 응답을 하지 않고 있다. 乙의 행위가 위법한 부작위에 해당하는지에 대하여 설명하시오. (25점)》

### <문제3> 공사중지명령 철회신청에 대한 무응답 행위의 위법 부작위 해당 여부

#### I. 문제의 제기

- 사안에서 A시 시장 乙은 甲에 대한 공사중지명령 후 원인이 사유가 소멸하였다는 이유로 제기된 철회신청에 대하여 이를 받아들이지 않고 아무런 응답을 하지 않는 상황이다. 쟁점으로 <행정청이 철회신청에 대하여 응답하지 않은 것이 항고소송의 대상이 되는 위법한 부작위에 해당하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙의 행위가 위법한 부작위에 해당하는지에 대해 설명한다.

#### II. 부작위의 성립 조건과 신청권의 법리

##### 1. 행정소송법상 부작위의 성립 요건

###### (1) 부작위의 정의 및 범위

- 행정소송법 제2조 제1항 제2호는 부작위를 행정청이 당사자의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 것으로 규정하고 있다.

###### (2) 부작위의 4대 성립 요건

- 행정소송법상 처분의 부작위가 성립하여 사법심사의 대상이 되기 위해서는 ① 당사자로부터 구체적인 처분의 신청이 존재할 것, ② 행정청에게 일정한 처분을 행하여야 할 공법상 작위 의무가 존재할 것, ③ 처분을 내리기에 상당한 기간이 경과하였을 것, ④ 행정청의 처분 등 어떠한 공권력 행사도 부존재할 것이라는 요건을 누적적으로 충족하여야 한다.

##### 2. 법률상 신청권의 요구와 도출 근거

###### (1) 법률상 신청권의 필요성

- 대법원은 행정소송법상 부작위가 성립하기 위해서는 단순히 당사자가 처분을 신청한 사실만으로는 부족하며, 그 당사자에게 행정청의 공권력 발령을 요구할 수 있는 구체적인 법률상 신청권이 귀속되어 있어야 한다고 일관되게 판단한다. 법률상 신청권이 없는 제3자 등의 단순한 민원이나 진정에 대하여 행정청이 무응답으로 일관하더라도 이는 소송법상 부작위가 될 수 없다.

###### (2) 신청권의 구체적 도출 경로

- 처분을 요구할 수 있는 신청권은 성문법상 명시적으로 규정되어 있는 경우뿐만 아니라, 개별 법령의 합리적인 해석을 통해 도출되거나 행정법의 일반 원칙에 근거한 조리(條理)를 통해서도 예외적·보충적으로 인정될 수 있다.

##### 3. 공사중지명령의 해소와 조리상 철회신청권

###### (1) 침익적 처분의 지속 요건과 실체법적 한계

- 공사중지명령과 같은 제재적·침익적 행정처분은 처분 당시는 물론이고 그 집행 및 효력이 유지되는 전 과정에 걸쳐 실체법상 적법 사유가 계속해서 존재하여야 한다. 만약 처분 발령 이후 사정변경으로 인하여 제재의 원인이 되었던 법령 위반 등 비위 상태가 완전히 해소되었다면, 해당 명령을 유지할 실체법적 근거는 상실된다.

###### (2) 조리상 철회신청권에 관한 판례의 태도

- 대법원은 공사중지명령을 받은 처분의 상대방은 그 명령의 원인이 사유가 완전히 해소되었다면 처분청에 대하여 공사중지명령의 철회를 신청할 수 있는 조리상 신청권을 가진다고 판시하여 조리상 권리의 존재를 명백히 긍정하고 있다. 행정청의 철회의무에 대응하는 신청인의 적극적 권리를 인정함으로써 사법적 구제의 기틀을 제공한 것이다.

#### III. 사안의 적용

##### 1. 甲의 조리상 철회신청권 취득 여부

###### (1) 철회신청의 구체성 확보

- 사안에서 공사중지명령의 상대방인 甲은 단순한 행정지도나 질의를 한 것이 아니라, 명령 발령의 원인이 사유가 소멸하였음을 직접 주장하며 乙에게 구체적으로 공사중지명령의 철회를 구하는 처분을 신청하였다.

###### (2) 판례에 따른 조리상 신청권의 성립

- 공사중지명령의 원인이 사유가 해소되었다면 甲에게는 처분의 효력을 거두어 줄 것을 청구할 수 있는 조리상 신청권이 귀속된다. 따라서 甲은 乙에 대하여 정당한 사법적 응답을 요구할 수 있는 소송법상 적격 있는 신청권자에 해당한다.

##### 2. 乙의 무응답 행위의 위법 부작위 해당성

###### (1) 乙의 법적 작위 의무의 존재

- 甲의 정당한 조리상 신청권 행사에 대응하여, A시 시장 乙은 실제로 원인이 사유가 소멸하였는지를 충실히 심사하여 처분을 철회해 주거나, 여전히 소멸하지 않았다고 판단될 경우 신청을 거부하는 처분을 대외적으로 발령해야 할 공법상 답변 의무(작위 의무)를 부담하게 된다.

###### (2) 상당 기간의 도과 및 무조치 상태의 완성

- 그럼에도 불구하고 乙은 甲의 신청에 대하여 상당한 기간이 경과하기까지 철회처분도, 거부처분도 행하지 않은 채 어떠한 의사표시도 없이 무응답으로 방치하고 있다. 이는 법적 의무를 해태한 무조치 상태이므로 행정소송법상 부작위 성립 요건을 완벽히 충족한다.

#### IV. 결론

- A시 시장 乙이 甲의 공사중지명령 철회신청에 대하여 무조치 및 무응답으로 일관한 행위는 행정소송법 제2조 제1항 제2호 소정의 위법한 부작위에 해당한다. 대법원 판례에 따라 제재적 처분의 상대방에게는 사정변경에 따른 조리상 철회신청권이 인정되고, 행정청에게는 그에 알맞은 응답을 해 줄 작위 의무가 발생하기 때문이다. 결론적으로 乙의 방치는 사법적 권리구제의 대상이 되는 위법한 부작위가 되므로, 甲은 乙을 피고로 삼아 관할 행정법원에 부작위위법확인소송을 적법하게 제기하여 권리구제를 도모할 수 있다.